

1506226-86.2021.8.26.0526

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Comarca: Salto

Foro: Foro de Salto

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2134377/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17971369 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1279/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2134377 - DEL.POL.SALTO, 1279/21/610 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Salto

Foro de Salto

3ª Vara

Av. Dom Pedro II, 261, Salto-SP - cep 13320-240

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1506226-86.2021.8.26.0526 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506226-86.2021.8.26.0526

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2134377/2021 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 17971369 - DEL.POL.PLANTÃO ITU, 1279/21/610 -

DEL.POL.PLANTÃO ITU, 2134377 - DEL.POL.SALTO, 1279/21/610 - DEL.POL.SALTO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEAN MORAES DA SILVA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALVARO AMORIM DOURADO LAVINSKY

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público contra os réus JEAN MORAES DA SILVA e RODRIGO EVANGELISTA LADISLAU, qualificados nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal l c.c. art. 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública), do Código Penal, porque em tese, em data incerta, anterior ao dia 17 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Lins, nº 01, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto/SP, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico ilegal de drogas.

Consta ainda que, no dia 17 de maio de 2021, por volta das 21h30min, na Rua Lins, nº 01, Jardim Marília I, nesta cidade e comarca de Salto/SP, os acusados, agindo em concurso, previamente associados e em unidade de desígnios, guardavam e traziam consigo, para entrega a consumo e fornecimento, ainda que gratuito, 190 (cento e noventa) porções de "cocaína", com peso líquido de 22,15g (vinte e dois gramas e

quinze centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

As prisões em flagrante foram convertidas em preventivas (fls. 71-74).

Os réus foram notificados pessoalmente (fls. 133 e 135) e apresentaram defesas prévias (fls. 160-161 e 162-163).

A denúncia (fls. 106-111) foi recebida em 26 de agosto de 2021 (fls. 165-166) e os acusados foram citados pessoalmente.

Revogada as prisões preventivas pelo C STJ, foram expedidos alvarás de soltura às fls. 147-148 e 149-150.

Em fase de instrução processual foram inquiridas três testemunhas comuns e os réus foram interrogados.

Em alegações finais por memoriais, o representante do Ministério Público requereu a parcial procedência da ação penal para condenar os réus por infração ao artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pleiteando, todavia, a absolvição pela ausência de provas quanto ao crime previsto no artigo 35 da mesma Lei.

A Defesa de Jean Moraes da Silva ofereceu alegações finais (fls. 354- 421) requerendo absolvição com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, apontando que a prova derivada da busca pessoal e domiciliar é ilícita e deveria ser desconsiderada por violação de direitos fundamentais e, alternativamente, absolvição ante a insuficiência de provas ou fixação da pena base no mínimo legal, que se considere a atenuante da menoridade e a causa de diminuição pena prevista no o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; haja imposição de regime prisional aberto e substituição pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa de Rodrigo Evangelista Ladislau requereu a absolvição por falta de provas; aplicação da pena no patamar mínimo; reconhecimento da atenuante da menoridade; seja considerada a causa de diminuição pena prevista no o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06; início de cumprimento de pena em regime menos gravoso e, ainda, aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, por fim, pleiteia para que seja deferido ao réu apelar em liberdade.

É o relatório do essencial.

Fundamento e decido.

Não há qualquer mácula na atuação dos agentes públicos, qualquer do povo pode realizar e os agentes devem efetuar a prisão em flagrante (art. 301 do CPP), sendo que o tráfico de drogas é delito permanente. Os policiais militares, exercendo a função de polícia preventiva e ostensiva (art. 144, § 5º, da CF) podem, evidentemente, realizar revista veicular, já que havia fundada suspeita (art. 244 do CPP), considerando que os suspeitos demonstraram nervosismo após aproximação da viatura e especialmente pelo fato de eles estarem no interior de um veículo estacionado na contramão da via, em local conhecido pela venda de entorpecentes, vide depoimento mencionado abaixo. Na mesma linha de entendimento:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.

GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENHIDA.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS.

IMPOSSIBILIDADE. REVISTA VEICULAR. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ALTERAÇÃO DO

ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO

FÁTICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO NAS

DROGAS ENCONTRADAS NOS VEÍCULOS E NÃO NA RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO

ILEGAL. ORDEM DENEGADA. A validade da segregação cautelar está condicionada à

observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art.

312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em

que consiste o periculum libertatis. No caso, a prisão preventiva está justificada pois, segundo a decisão que a impôs, o paciente foi flagrado com elevada quantidade de substância entorpecente (5kg de cocaína). Dessarte, evidenciada a sua

periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem

pública. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a

prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a

decretação da segregação provisória (precedente). Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na

gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Com relação à busca veicular, sabe-se que esta Corte Superior a equipara à busca pessoal, e o art. 244 do CPP assevera que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar". 6. No presente caso, a Corte de origem consignou que "não só as informações recebidas pelos policiais, mas também a atitude do paciente [...] teria levado a abordagem". Dessa forma, delineada no acórdão a existência de informações policiais; e no auto de prisão em flagrante, a realização de investigações, tem-se que a alteração de tal entendimento demandaria análise fático-probatória, o que é vedado na via do habeas corpus. 7. Por fim, com relação à alegação de violação de domicílio, destaco que mesmo o reconhecimento de tal ilegalidade não justificaria a revogação da prisão preventiva, já que essa, como se viu, está fundamentada na quantidade de entorpecentes apreendidos dentro de veículos que estavam fora da residência. 8. Ordem denegada. (HC 691.441/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2022, DJe 26/04/2022)

Além disso, os policiais entraram no apartamento durante perseguição a Jean, em situação de flagrante delito, observados os artigos 5º, XI, da Constituição Federal e 302, inciso III, e 303 do Código de Processo Penal.

No mérito, a pretensão punitiva estatal merece parcial procedência.

A materialidade do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 01), boletim de ocorrência (fls. 02/06), auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 19/21), laudo de exame químico toxicológico (fls. 94/96), tudo em harmonia com a prova coligida nos autos.

A transcrição dos depoimentos encontra-se em fls. 195-272.

A testemunha comum Giovani Silveira Bignoto, policial militar, em Juízo relatou, em síntese, que os policiais estavam em patrulhamento de rotina em ponto conhecido pela venda de entorpecentes. Não sabia do envolvimento dos réus no tráfico. Viram um veículo branco estacionado na contramão de direção, quando se aproximaram, notaram que os três passageiros esboçaram nervosismo, um deles tentou descer do carro e retornou, o que levantou suspeitas. Feita a busca pessoal nos três, o motorista identificado como Eric Martins Pontes se apresentou como Uber, nada de ilícito localizado com ele, apenas quantia em dinheiro. Disse não saber que os demais portavam entorpecentes, sendo liberado na delegacia. Com um dos passageiros, que não se recorda o nome, foi localizado na jaqueta certa quantidade de entorpecente, embrulhado em uma sacola e ele disse aos policiais que havia sido preso por tráfico de drogas anteriormente. O outro indivíduo, posteriormente identificado como sendo Jean Moraes da Silva, empreendeu fuga a pé, deixando cair um rastro de entorpecente, sendo perseguido por outros dois policiais e tendo sido abordado no interior de um apartamento do Conjunto Habitacional Rio Branco e os entorpecentes recuperados, inclusive, idênticos àqueles localizados na posse de Rodrigo. Viu Jean dispensando o entorpecente. Relatou ao policial que ficou com medo e fugiu, mas não admitiu a propriedade dos entorpecentes. Os policiais não mostraram a droga localizada com Rodrigo para os demais, mas acredita que viram pois Jean saiu correndo. Os revistados ficaram um do lado do outro. A policial Dias localizou a droga e lhe entregou, na sequência ela correu para alcançar o que fugiu.

A testemunha comum, Carolina Dias Ribeiro, policial militar, disse, em resumo, que estavam realizando patrulhamento de rotina e visualizaram um veículo branco estacionado com três indivíduos e, por não acharem normal, até pelo horário, tendo eles demonstrado nervosismo, resolveram abordar. Realizou a busca pessoal, com o Uber, nada de ilícito foi encontrado, na jaqueta de Rodrigo localizou cento e poucos pinos de cocaína e, o outro, de nome Jean, correu, dispensando pinos pelo caminho, idênticos aos encontrados com Rodrigo. Deixou a droga com outro policial e foi ao encalço de Jean. Viu quando ele entrou nos prédios, retornou ao local da abordagem para pedir apoio e o colega continuou na perseguição. Ficou na viatura.

Chegou o apoio e ele foi localizado dentro de um apartamento. Não tinha conhecimento de denúncias anteriores relacionando-os ao tráfico nem os conhecia. Não fez a entrevista com o Uber. Não sabe de Jean ficou fora da visibilidade dos policiais e nem se foram encontrados entorpecentes dentro do apartamento em que ele estava. Não se lembra de ter feito a revista no Uber. Acredita ter demorado vinte minutos para localizar Jean no apartamento. Não se recorda onde o Uber ficou esperando.

A testemunha comum Eric Martins Pontes, motorista de Uber, disse que estacionou o carro na frente do CDHU e os indivíduos, que não conhecia, pediram a corrida. Foram até a rua de trás esperar, momento em que foram abordados e revistados pelos policiais. Não ouviu nenhum comentário diferente dos indivíduos e nenhum estava nervoso. Os três ficaram um do lado do outro, cerca de um metro e meio, dois metros de distância, estava do lado esquerdo. Foi revistado por um homem e os demais, não se lembra se foram revistados pela mesma pessoa. Não viu e nem ouviu se tinham localizado entorpecentes com os demais. Viu quando um deles correu. Não viu se ele dispensou algo. A policial feminina não correu em perseguição. Foi colocado na viatura e levado para o conjunto habitacional, antes de ir para delegacia, mas não conseguiu ver nada. Chegou na delegacia antes dos outros dois. Não sabe se eram usuários. Não teve conhecimento, na delegacia, sobre os entorpecentes. Tinha cerca de quinhentos reais referente às corridas do aplicativo. Estava estacionado na contramão. Não teve mais contato com os demais.

Interrogado, o réu Jean Moraes da Silva, disse que Rodrigo e ele pegaram um Uber que estava parado na frente dos prédios. Pararam na rua de trás para esperar o primo. A viatura parou ao lado do carro, mandaram todos descer com a mão na cabeça. Não estavam nervosos. Ficou de frente para o muro, do lado esquerdo, Rodrigo no meio e Eric o primeiro. Rodrigo não estava com droga. O pressionaram para entregar alguém que tinha droga. O ameaçaram e bateram nele. Não aguentou mais e saiu correndo para tentar chegar na casa da mãe, um policial foi atrás dele. Antes de correr, foi revistado por um homem e a policial feminina não revistou ninguém. O policial percebeu em qual bloco entrou, não sabendo precisar em qual apartamento. Foi pego na porta do apartamento de um amigo da mãe, quando estava saindo, sendo determinado pelo policial que voltasse para dentro do apartamento e bateram nele, por cerca de quarenta minutos. Demorou meia hora para os policiais o localizarem. Não chegou ao apartamento da mãe pois ficou com medo de apanhar na frente da mãe. O amigo da mãe permitiu sua entrada no apartamento e o viu apanhar. Quando saiu do apartamento com os policiais, havia quatro viaturas, uma delas com Rodrigo, sendo que o Uber não conseguiu visualizar. Chegou na delegacia junto com Rodrigo e o Uber já estava lá. Disse não conhecer os policiais.

Interrogado, o réu Rodrigo Evangelista Ladislau, disse que ele e Jean pegaram um Uber que estava estacionado na frente dos prédios. Pararam na frente da casa de Fernando para ele ir também, nesse momento foram abordados pelos policiais. Ficaram lado a lado, de frente para a parede, tendo ele ficado no meio, sendo revistados por um policial. A policial feminina estava dentro do carro. Depois que falaram que moravam nos prédios, os policiais começaram a bater neles e perguntar sobre pessoas que vendiam drogas, o que foi respondido que não sabiam. Jean saiu correndo para avisar os familiares, sendo perseguido por um policial. Já haviam sido revistados, nesse momento, não sendo encontrada droga com nenhum dos três, não sabe de onde surgiu a droga apreendida. Continuaram lhe batendo e perguntando onde Jean morava. Foi colocado na viatura e levado para os prédios do CDHU cerca de duas a três horas. O Uber estava em outra viatura, mas ao entrarem nos prédios, não o avistou mais. Jean foi localizado e foram levados para delegacia. Não os informaram porque os levariam presos. Não conhecia os policiais. Já foi usuário de maconha e cocaína.

Os policiais apresentaram versão firme, coerente e rica em detalhes demonstrando que os réus guardavam e traziam consigo a droga e, após abordagem e revista pessoal, foi localizada mais de uma centena de pinos de cocaína nas vestes de Rodrigo, ao passo que Jean correu, dispensando demais pinos pelo caminho. As declarações de policiais possuem relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição, e apoiados nos demais elementos de prova, como na

hipótese. Finalmente, não há qualquer indício de prova que autorize concluir que os guardas tenham mentido para prejudicar o réu. Nesse sentido:

"As declarações dos agentes estatais, a princípio, são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé, o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu valor probante (Ap. Crim. (Réu Preso) n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela. Desa. Salete Silva Sommariva)."

A discrepância apontada pela Defesa em relação ao depoimento dos policiais, verbis: "Excelência, porque quando da suposta localização da droga na posse de Rodrigo, e não foi mostrado para o motorista do Uber? Porque então o motorista do Uber foi levado até a delegacia se não foi encontrado com nada? Resposta do Policial que é protocolo não mostrar os entorpecentes para todos que estão ali no local, nota-se que não tem nenhuma coerência. Porque a Policial Carolina disse não ter revistado o motorista do Uber e na delegacia disse que sim? Sempre respondendo não me recordo.", além de não de não determinantes na apuração da autoria do crime, são aceitáveis em razão do decurso do tempo e falibilidade humana. O discurso artificialmente uniforme, longe de demonstrar veracidade, denotaria, em tese, que o depoente presta discurso ensaiado e mentiroso.

Em que pese a negativa de autoria pelos acusados, certo é que os demais depoimentos colhidos em conjunto com as provas materiais produzidas, são suficientes a embasar o decreto condenatório, haja vista que os policiais militares localizaram com o acusado Rodrigo mais de cem pinos de cocaína, aliado ao fato de que, na sequência, o correu Jean empreendeu fuga, dispensando demais pinos de cocaína pelo caminho, idênticos ao encontrado com Rodrigo, consoante se observa do laudo pericial fls. 94-96, não sendo crível que tais pessoas mentissem apenas para prejudicar os réus. A versão dos réus de que o flagrante foi forjado não possui qualquer amparo na prova produzida nos autos. Nota-se que a testemunha Eric se limitou a dizer que não viu e nem ouviu se os policiais localizaram entorpecentes com os demais, não afirmando que não foram, efetivamente, encontrados entorpecentes. A respeito do ônus da prova em relação a fato novo suscitado pelo réu, confira-se a afirmação de Guilherme de Souza Nucci in Provas no Processo Penal (2015; p.35):

"Ao réu, se pretende apenas negar a imputação, resta permanecer inerte, pois nenhum ônus lhe cabe. Seu estado de inocência prevalece. Entretanto, se a estratégia de defesa tiver por meta alegar fato diferenciado daqueles constantes da denúncia ou queixa, chama a si o ônus da prova. É o que, naturalmente, ocorre com a sustentação do alibi (dizer que estava em local diverso daquele onde aconteceu o crime). Buscará o acusado, por interesse seu, demonstrar ao juiz a autenticidade de sua informação. Cabe-lhe o encargo, a responsabilidade. Não demonstrado o alibi, permanece o réu na sua condição de inocente, mas, provavelmente, a acusação conseguirá avançar, ainda mais, na sua linha de demonstração de que ele é culpado."

Com relação ao crime de associação para o tráfico tem-se que é um delito autônomo. Para que alguém responda por este crime são necessários os seguintes elementos: a) duas ou mais pessoas; b) acordo dos parceiros; c) vínculo associativo; d) finalidade de traficar tóxicos.

As provas coligidas aos autos não foram aptas a demonstrar um mínimo de organização e planejamento prévio para a prática da associação criminosa, consoante observado em alegações finais pelo Ministério Público. Assim, a absolvição pelo crime de associação ao tráfico é medida que se impõe.

Para fins de dosimetria, destaco que o processo em curso em relação ao réu Rodrigo (fl. 185) não constitui maus antecedentes. Nesse sentido, o Plenário do STF, em julgamento de repercussão geral, firmou o entendimento de que: "PENAL- FIXAÇÃO - ANTECEDENTES CRIMINAIS - INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO - DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais". (STF RE 591054). O mesmo posicionamento foi cristalizado pelo Enunciado nº 444 da Súmula do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base".

No que se refere à agravante do art. 61, inciso II, alínea "j", inexistem elementos que indicam que o réu tivesse se aproveitado da situação de calamidade pública para praticar o delito. Não houve, portanto, aproveitamento, pelo réu, daquela situação o que, na hipótese positiva, poderia sim conferir uma maior reprovabilidade à ação. Conforme julgou o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"O contexto de calamidade pública, ainda que decretado pelo Poder Público, não é apto à caracterização da agravante, no caso presente, a não ser que, v. g., se estivesse em cenário particularizado, como a falsificação de uma vacina ou o descumprimento de medida sanitária preventiva." (Apelação Criminal nº 1501808-87.2021.8.26.0047, Relator: Guilherme de Souza Nucci.)

O Plenário do STF, no julgamento dos habeas corpus nº 112.776 e nº 109.193, consolidou entendimento segundo o qual "configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para se fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º, do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)". Importante salientar que as causas de diminuição de pena são mais relevantes que as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, de caráter nitidamente residual.

Portanto, se o juiz notar um fator de destaque no crime cometido pelo traficante primário e de bons antecedentes, sem ligações criminosas, como pequena quantidade da droga, deve utilizar esse critério para operar maior diminuição (ex.: dois terços), deixando de considerá-la para a fixação da pena-base. O contrário também se dá.

Na hipótese analisada, a quantidade apreendida é pouco expressiva: 22,15 gramas de cocaína e o processo em curso (fl. 191) não é considerado como mau antecedente ou reincidência, os réus são primários (fls. 182 e 185 ) e não restou provado que integram organização criminosa, considerando que as prisões decorreram de abordagem de policiais militares sem qualquer investigação prévia; tudo a justificar a incidência da causa de diminuição em grau máximo. Salientando-se que a prática de prévio ato infracional também não constitui maus antecedentes e não impede a aplicação do mencionado redutor. Nesse sentido, tem-se a jurisprudência:

APELAÇÃO (recurso apenas defensivo) – Tráfico de entorpecente – Pleito da Justiça Gratuita atendido. "A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça" (§ 4º do art. 99 do NCPC), anotando-se, porém, na esteira do sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, que "A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos" e que "a análise da miserabilidade do condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções", até porque pode sobrevir, naquele lustro, "mudança na situação econômica da beneficiária" – No mais, materialidade e autoria delitivas comprovadas – Sem olvido de que "Toda pessoa poderá ser testemunha" (art. 202 do CPP) – , nada foi comprovado em pretório (art. 156 do CPP) que demonstrasse qualquer equívoco, animosidade ou inimizade a retirar a credibilidade da prova testemunhal policial, não se podendo inferir, pois, que houvesse na espécie incriminação sem justo motivo. Seria um contrassenso a sociedade organizada (Estado) arregimentar pessoas para a atividade policial e depois negar-lhes valia no trabalho realizado. Ademais, existe, in casu, testemunha civil também a incriminar a ré – Em casos dessa ordem, onde a traficância imputada não é na modalidade "vender", em nada beneficia a acusada o fato de ela não ter sido avistada contatando outras pessoas e/ou vendendo-lhes o estupefaciente, nem mesmo a circunstância de nenhum tóxico ter sido encontrado em seu poder no momento da abordagem policial, eis que a increpação é de que ela "guardava" e "tinha em depósito" a droga, afigurando-se desnecessário saber, inclusive, de quem era a propriedade respectiva, posto que, onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo – Comprovada a narcotraficância irrogada, impossível a desclassificação para a infração do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006 – Tráfico Privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006).

Cabimento. Como processos e/ou inquéritos em curso não podem ser considerados na fixação da pena-base, em face do princípio constitucional da presunção de inocência (CF, art.5º, LVII), pela mesma razão também não se afiguram aptos a obstaculizar, ainda no momento dosimétrico (terceira etapa), a figura privilegiada (onde existe a mesma razão, aí há o mesmo direito: ubi eadem ratio ibi idem ius). (STF e STJ) – Indemonstradas circunstâncias outras a obstar a benesse legal, a aplicação de tal redutor legiferado deve se dar no máximo legal (2/3), dado que o tóxico apreendido o foi em pequena quantidade (menos de 4 gramas de crack), com regime inicial aberto (diante da favorabilidade das circunstâncias judiciais, da primariedade e do quantitativo sancionatório), como necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime no caso concreto (CP, art. 33, §2º, "c", e §3º, c.c. o art. 59, caput, in fine, e III, e com o artigo 42 da Lei de Drogas) – Inconstitucionalidade do valor da pena de multa prevista na Lei Antidrogas – Inocorrência. A Lei nº 11.343/2006 é especial em relação ao Estatuto Repressivo (art. 49), de modo que, com rigores sancionatórios ínsitos à inafastável necessidade de se tutelar a saúde pública, deve prevalecer sobre a regra geral (lex specialis derogat legi generali), sem qualquer inconstitucionalidade, até porque editada pelo Poder Legislativo, a quem cabe, na sua tarefa de satisfação do interesse público, não só definir os tipos penais, mas também estabelecer as respectivas sanções. Toda e qualquer punição estatal advinda de condenação criminal repercute, de uma maneira ou de outra, no ius ambulandi do sentenciado, com inegável reverberação econômica não só à sua pessoa, como também àquelas que dele monetariamente dependam. Mas isso não pode significar, por óbvio, violação à intranscendência subjetiva das sanções, albergada no artigo 5º, XLV, da Constituição da República; as normas constitucionais não comportam interpretações estanques, devendo coexistir contextualmente, e, assim, também permitir a apenação daqueles que infringirem a normatividade penal posta, como se depreende de vários dos incisos hospedados naquele mesmo artigo 5º. Tem-se, nesse contexto, a busca do primado maior da Justiça, de se dar a cada um o que é seu (suum cuique tribuere), inclusive individualizando-se a pena, como expressamente contemplado no citado artigo 5º, desta feita no inciso XLVI, e dessa forma possibilitar o respeito à harmonia e ao bem-estar sociais, consoante o preâmbulo da mesma Lei das Leis – Presentes os requisitos legais, cabível a substituição da pena corporal por duas restritiva de direitos, a teor da segunda parte do § 2º (quantum superior a 1 ano) do artigo 44 do Código Penal, a serem estabelecidas pelo Juízo da Execução Penal. Inviável tal permuta "por multa"; diversamente, se estaria desnaturando a mens legis, que cominou à espécie, cumulativamente, reprimenda prisional e (também) multa, de maneira que a aplicação de uma nova pena de multa não se afigura socialmente recomendável em casos que tais, pois, em última análise, ter-se-ia como resultado somente sanção pecuniária (STJ) – DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Criminal 1501447-21.2019.8.26.0571; Relator (a): Adilson Paukoski Simoni; Órgão Julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Tatuí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 20/07/2021; Data de Registro: 20/07/2021). Assim, satisfatoriamente comprovadas a materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, passo a dosagem das penas.

JEAN MORAES DA SILVA

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é primário, culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante do art. 61, inciso II, alínea "j" e presentes as atenuantes da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea

'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

RODRIGO EVANGELISTA LADISLAU

Analisada as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o réu é tecnicamente primário (fl.185), culpabilidade, conduta social, personalidade do agente, motivos são normais à espécie, as circunstâncias e consequências do crime, não podem ser valorados negativamente, razão pela qual fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, ausente agravante do art. 61, inciso II, alínea "j" e presentes as atenuantes da menoridade, porém, mantenho a pena no mínimo legal, conforme súmula 231 do STJ.

Considerando a primariedade e o não envolvimento do réu com nenhuma organização criminosa, com fundamento no §4º do art. 33 da Lei de Tóxicos, reduzo a pena em 2/3, obtendo a pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Diante da quantidade de pena aplicada, o regime é o aberto (artigo 33, §2º, alínea 'c' e §3º, do Código Penal).

Atendidas as condições previstas no art. 44, incisos I a III, e art. 77, "caput", inc. III, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade pelo mesmo prazo da pena original, a ser especificada em sede de execução penal e prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para:

1) CONDENAR o réu JEAN MORAES DA SILVA, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, observada a substituição da pena; ABSOLVER o réu JEAN MORAES DA SILVA da prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; 2) CONDENAR o réu RODRIGO EVANGELISTA LADISLAU, qualificado nos autos, pela prática do crime previsto nos artigos 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, na pena de 1 (um) ano, 8 (oito) meses e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com valor unitário fixado no patamar mínimo legal, observada a substituição da pena; ABSOLVER o réu RODRIGO EVANGELISTA LADISLAU da prática do crime previsto no artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Concedo a interposição de recurso em liberdade, diante da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direito e regime aplicado.

Após o trânsito em julgado: (i) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, na forma do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; (ii) expeça-se a guia para execução, devendo a pena de multa ser cobrada nestes autos e (iii) expeça-se certidão de honorários advocatícios no correspondente item da tabela do convênio OAB - Defensoria/SP ao advogado dativo, para retirada exclusivamente pela internet.

Oportunamente, ao arquivo.

Publique-se e intime(m)-se.

Salto, 26 de abril de 2022.